

1503309-81.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga - em que pese, no caso dos autos, atos de comércio ilícito tenham sido observados pelos policiais civis -, estando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico nas modalidades de "trazer consigo" e "guardar" os entorpecentes.

Ainda, bem demonstrada a causa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503309-81.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503309-81.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLAMS AUGUSTO DA SILVA SERAFIM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

WILLAMS AUGUSTO DA SILVA SERAFIM foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 09 de fevereiro de 2022, por volta das 11h10min, na Estrada dos Mirandas, altura do numeral 846, Campo Limpo, nesta Cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o adolescente infrator Wellington Santos de Almeida, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 19 (dezenove e nove) invólucros contendo um total de 67,2g de maconha -Tetrahydrocannabinol; 40 (quarenta) invólucros contendo um total de 5,7g de cocaína do tipo "crack"; 62 (sessenta e dois) invólucros contendo um total de 18,2g de cocaína, bem como 12 frascos contendo um total de 87,5ml de lança-perfume - Tricloroetileno, substâncias essas capazes de causar dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a Denúncia, o acusado foi citado, apresentando Resposta à Acusação, seguindo-se a decisão saneadora.

Em audiência foi colhida a prova oral e interrogado o acionado.

Ponderações finais das partes em debates.

Auto de Exibição e Apreensão do Entorpecente, a fls. 06/07.

Laudo de Constatação a fls. 12/15.

Laudo de Exame Químico-Toxicológico, a fls. 129/131.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, bom consignar que descabe ao magistrado impor ao órgão do Ministério Público contratar com o acionado o ANPP, sem amparo na Lei.

Ao oferecer a denúncia a representante Ministerial apresentou seus motivos, negando a oportunidade do ANPP, (fls. 56, item 5).

Citado, o acionado apresentou resposta escrita, sede em que silenciou, inclusive, quanto a oportunidade conferida pelo art. 28-A, § 14, do CPP.

Logo, a este momento, descabe qualquer outra providência, máxime porque, consoante coloquei acima, como equidistante das partes, num processo acusatório, descabe ao magistrado interferir na esfera de disposição das partes para ajuste.

Como o magistrado não pode impor a qualquer acionado aceitar um benefício eventualmente proposto pelo órgão de Acusação, não pode, também, impor ao órgão de Acusação oferecer benesse, principalmente da espécie negócio jurídico de natureza extrajudicial.

Muito menos, ainda, substituir-se à figura do Ministério Público.

Sobre o tema, confira-se: A ordem não pode ser concedida. O Acordo de Não Persecução Penal ANPP, instituído no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 13.964/19, popularmente conhecido como “Pacote Anticrime”, é prerrogativa do Ministério Público, conforme expressamente dispõe o caput do art. 28-A do Código de Processo Penal (grifos nossos): “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente”: O mesmo dispositivo processual penal prevê, no § 14: “§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”. A possibilidade de interferência do Judiciário nessa prerrogativa é bastante limitada, prevista nos §§ 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, do mesmo art. 28-A do Código de Processo Penal (grifos nossos): “§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade. § 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. § 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. § 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo. § 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia”. Como o Acordo de Não Persecução Penal ANPP foi negado pelas duas instâncias do Ministério Público, não há possibilidade legal de intervenção do Poder Judiciário nesse tema, o qual, volto a frisar, é prerrogativa da Justiça Pública. No mais, não se vislumbra nos autos qualquer constrangimento passível de ser corrigido por meio do remédio heroico. Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem. (Habeas Corpus Criminal nº 2058982-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 18 de maio de 2020, rel. Desembargador CAMILO LÉLLIS); Pois bem. Em prelúdio, como frisado pelo Ministério Público que atua no Juízo a quo, e nos exatos termos da lei, deve o MP entender que o acordo é necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, o que não restou configurado no caso em tela. Conforme lição de Renato Brasileiro de Lima em sua

obra Manual de Processo Penal , 8ª edição, 2020, Editora Juspodivm, o acordo de não persecução penal, introduzido pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), cuida de negócio jurídico de natureza extrajudicial, necessariamente homologado pelo juízo competente, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso (devidamente assistido por seu defensor), o qual confessa formal e circunstanciadamente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade, em troca do compromisso do parquet de não perseguir judicialmente o caso penal extraído da investigação penal, leia-se, não oferecer denúncia, declarando-se a extinção da punibilidade caso a avença seja integralmente cumprida. Dessa forma, deve-se partir da premissa de que o acordo de não persecução penal deve ser resultante da convergência de vontades (acusado e MP), não podendo se afirmar, indubitavelmente, que se trata de um direito subjetivo do acusado, até porque, se assim fosse, haveria a possibilidade do juízo competente determinar a sua realização de ofício, o que retiraria a sua característica mais essencial, que é o consenso entre os sujeitos envolvidos. Ademais, o legislador previu no art. 28-A, §14, que diante da negativa do Ministério Público em oferecer o referido acordo, pode o magistrado remeter os autos ao i. Procurador Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do CPP, o que de fato foi feito nestes autos, conforme podemos verificar às fls. 35/41. No entanto, o digno Procurador Geral de Justiça manteve a posição do Promotor de primeiro grau e insistiu na recusa de oferta do referido acordo. Logo, todas as medidas possíveis ao Poder Judiciário foram tomadas para eventual realização do referido acordo, não sendo possível exigir que o Ministério Público o ofereça após a confirmação da recusa por seu órgão máximo. Com efeito, cabe observar que com o Estatuto Anticrime o nosso ordenamento processual penal deu uma inquestionável guinada no sentido do sistema acusatório puro, colocando o juiz em posição menos interferente no que toca à formulação da acusação. Ou seja, o juiz até pode aplicar o art. 28 do CPP por força do disposto no parágrafo 14 do novo art. 28-A, mas não pode, em sendo mantida a recusa do MP, ir além disso, até porque, se bem observada a nova redação do art. 28 (também por força da Lei 13.964/19 Estatuto Anticrime), o órgão do MP nem mais submete ao juiz a apreciação da sua ordem de arquivamento. Tanto é assim que já há precedentes neste e. Tribunal de Justiça no sentido de que o Poder Judiciário deve se abster de interferir na questão, conforme podemos observar do acórdão proferido pela 15ª Câmara Criminal, no julgamento do habeas corpus 2026314-51.2020.8.26.0000, de relatoria do Exmo. Des. Ricardo Sale Júnior: Acerca do acordo de não persecução penal, trata-se de uma discricionariedade do Ministério Público, eis que o artigo 28 A do Código de Processo Penal dispõe que: Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...). Ou seja, trata-se de um dispositivo legal não vinculante, não devendo o Poder Judiciário interferir na obrigatoriedade de sua aplicação. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2026314-51.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/04/2020; Data de Registro: 05/04/2020). Acresça-se que o reconhecimento da causa de diminuição de pena no delito de tráfico (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) impõe na maioria das vezes que haja o processo e dilação probatória para a constatação de todos os seus requisitos, o que, por si só, afastaria o ANPP pois se trata de forma de resolução penal pactuada pré-processual. Enfim, por este voto, DENEGA-SE A ORDEM. (Habeas Corpus Criminal nº 2075422-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 18 de maio de 2020, rel. Desembargador XISTO RANGEL); E circunscrita a competência do Poder Judiciário à análise da legalidade do oferecimento, ou não, da proposta de ANPP, conclui-se que o ato atacado não está maculado de ilegalidade, eis que de modo correto e adequado verificou a formalidade legal do não oferecimento, pelo Ministério Público, da proposta de acordo de não persecução penal que, como visto, está condizente com a disciplina legal acerca do instituto. Não há, por isso, que se reconhecer ilegalidade e nulidade no feito em

face da não apresentação de acordo de não persecução penal. Em conclusão, não se observa qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba - SP SP. Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem. (Habeas Corpus Criminal nº 2062921-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 27 de abril de 2020, Desembargador KLAUS MARQUELLI ARROYO)

No mesmo sentido: Habeas Corpus Criminal nº 2043590- 95.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 22 de abril de 2020, rel. Desembargador NEWTON NEVES; Habeas Corpus Criminal nº 2048237-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 17 de abril de 2020, rel. FRANÇA CARVALHO.

Afastada a questão preliminar, ao mérito, o que verdadeiramente interessa. A materialidade do crime encontra esteio no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 06/07, Laudo de Constatação de fls. 12/15 e Laudo Pericial de fls. 128/131, onde se infere que os materiais apreendidos com o acionado, se tratavam, efetivamente, de substâncias entorpecentes, no caso, maconha, cocaína, crack e lança-perfume. A autoria do crime de tráfico imputado ao acionado ecoa da prova produzida, evidenciada sua participação ativa na venda do entorpecente.

Interrogado na fase policial, o acionado silenciou, atitude que não se espera de quem se diz inocente (fls. 17).

Em Juízo, entendeu por bem negar a autoria criminosa nascotraficante.

Contudo, apresentou enredo fantasioso e inventivo, de todo embusteiro e inverossímil, revelador, unicamente, do espírito aguerrido e aventureiro do criminoso, de simplesmente pretender negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir.

Triste investida!

Doutro lado, temos os relatos precisos e harmônicos dos policiais civis responsáveis pela prisão do acusado.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, as testemunhas Thiago Magalhães dos Reis e Almerindo Oliveira Barreto Filho declararam, em versões de todo harmônicas que, na data em questão, receberam informação de que no local dos fatos, já conhecido como ponto de venda de drogas, havia dois indivíduos que estariam efetuando o comércio ilegal de tais substâncias, tendo um deles sido descrito como sendo pardo, de camisa polo listrada em verde e azul, enquanto o outro igualmente era pardo e trajava camiseta azul e branca. Na localidade, visualizaram dois indivíduos cujas características eram compatíveis com aquelas anteriormente descritas, os quais estavam praticando atos típicos do comércio de drogas. Relataram que o indivíduo que trajava camiseta azul recepcionou um aparente usuário de entorpecentes, recebeu valores e se direcionou até o outro, de camiseta polo listrada, entregando-lhe o dinheiro. Este, por sua vez, levantou uma madeira, abaixou-se e retornou com o que parecia se tratar de substância entorpecente. Neste cenário, absolutamente suspeito, resolveram efetuar a abordagem, identificando o indivíduo de camiseta listrada em verde e azul como WILLIAMS AUGUSTO DA SILVA, o qual entregou o entorpecente ao usuário, bem como o adolescente infrator, Wellington Santos de Almeida, como aquele que recebeu os valores do usuário. Em revista ao local, foi encontrado, debaixo do tapume anteriormente visualizado, uma sacola com diversos entorpecentes e uma quantia de valores em espécie, os quais foram apreendidos. Neste quadro, dúvida não me paira de que o acionado, acompanhado de seu comparsa mirim, trazia consigo e guardava drogas, consistentes em 19 (dezenove e nove) invólucros contendo um total de 67,2g de maconha (Tetrahydrocannabinol); 40 (quarenta) invólucros contendo um total de 5,7g de cocaína do tipo "crack"; 62 (sessenta e dois) invólucros contendo um total de 18,2g de cocaína; bem como 12 frascos contendo um total de 87,5ml de lança-perfume (Tricloroetileno), marcadamente destinadas à entrega para o consumo de terceiros, subdivididas em porções individuais, mormente porque não demonstrou condições econômicas para ter tamanha quantidade de drogas unicamente para seu deleite pessoal, sequer comprovando possuir emprego lícito.

Consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou

leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerassem suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

A grande quantidade de drogas apreendidas, num total de 133 (cento e trinta e três) porções de entorpecentes, a forma de armazenamento, acondicionadas em porções individuais, prontas para a venda no "varejo", a natureza das drogas, extremamente lesiva, dentre as quais destaco a cocaína e o crack, a apreensão de quantia de dinheiro em espécie, produto do comércio espúrio, as circunstâncias do flagrante, precedida a abordagem por campana policial, oportunidade em que foi o réu visualizado praticando atos típicos de traficância na companhia de seu assecla mirim, os depoimentos firmes dos policiais que abordaram o acusado e o seu comparsa menor de idade, enfim, todo o arcabouço probatório aponta para a conclusão inarredável deque o acusado efetivamente praticou a conduta criminosa que lhe é imputada pelo Órgão Ministerial.

De tal forma, da prova se extrai que efetivamente o réu praticou a conduta descrita na Denúncia, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Com efeito, irrelevante se mostra a não identificação precisa do cliente. Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga – em que pese, no caso dos autos, atos de comércio ilícito tenham sido observados pelos policiais civis –, estando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico nas modalidades de "trazer consigo" e "guardar" os entorpecentes.

Ainda, bem demonstrada a causa de aumento declinada na denúncia, na medida em que bem comprovada a cooptação do menor infrator Wellington Santos de Almeida (17 anos de idade) para a prática do tráfico, sendo de incidência, então, o disposto no art. 40, inciso VI, da Lei Federal nº 11.343/06.

Evidente a participação do menor no evento, decorrência da abordagem de ambos no palco dos acontecimentos, em situação absolutamente comprometedor, tendo sido visualizado em franca atividade de comércio de entorpecentes, aliado ao ora acusado.

Assim, as provas confirmaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o que confere um quadro de certeza quanto aos termos da imputação dada pelo Ministério Público.

Bem firmada a responsabilidade do réu pela prática da traficância, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais não se mostram absolutamente desfavoráveis, contudo, tendo em vista a considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, a diversidade das drogas e a natureza das substâncias, extremamente lesivas, fixo as penas do réu em patamar 1/6 superior ao mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, alcançando o cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias multa.

Em segunda fase, se mostram presente a circunstância agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, tendo em conta a data dos fatos (09.02.2022), e a edição do Decreto nº 64.879, de 20.03.2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, esta que, necessário consignar é de natureza objetiva, consoante leciona a doutrina: As circunstâncias agravantes genéricas são de caráter pessoal ou subjetivas, quanto: a) ao móbil do injusto ou à finalidade de agir (v.g.: motivo fútil ou torpe para facilitar ou assegurar a execução ou ocultação ou impunidade ou vantagem de outro injusto, ou por motivo de lucro); b) a qualidade ou condição pessoal do agente (embriaguez preordenada, com abuso do poder ou abuso de autoridade); c) quanto às relações do autor do ato com o sujeito passivo ou com os outros partícipes (parentesco, relações domésticas, de coabitação, ou hospitalidade; promovendo, organizando a cooperação ou dirigindo a atividade criminosa; instigando, coagindo a execução delitiva). Já as circunstâncias agravantes genéricas são de caráter objetivo, quanto: a) aos meios e modos de execução (traição, emboscada, dissimulação, emprego de veneno, fogo, explosivo,

tortura); ao tempo e lugar (por ocasião de incêndio, naufrágio, calamidade pública); c) à pessoa ou à condição da vítima (criança, velho, enfermo, pessoa sob estado de desgraça particular, ou pessoa sob imediata proteção da autoridade. (página 405, Direito Penal, Parte Geral, volume 3, 7ª edição, Álvaro Mayrink da Costa); O agente não cria, como na letra d, mas aproveita os efeitos da calamidade pública (além dos exemplos legais: seca, epidemia, guerra, extrema e geral carestia da vida, invasão armada, insurreição, certas greves, etc.) que, por natureza, atinge a coletividade, ou de calamidade particular (acidente, falência, infortúnios domésticos e pessoais em geral, etc.). Em todos os casos, a maior periculosidade define-se pela falta dos requisitos primários da solidariedade humana, pela completa ausência de senso moral. O agente não só desatende a imperativos éticos rudimentares, como não se detém diante dos supremos espetáculos da dor e do perigo, e ainda encontra neles sugestões e estímulos para aumentar a aflição dos aflitos. (página 299, Comentários ao Código Penal, volume 2, 2ª edição, Roberto Lyra); Situações de calamidade pública, como incêndios, inundações, ou mesmo naufrágios, ou de desgraça particular, como acidentes de trânsito, representam condições concretas adversas que reduzem ou excluem a capacidade de proteção pessoal ou patrimonial das vítimas, aumentando a reprovabilidade das ações lesivas de bem jurídicos penalmente protegidos. (página 578, Direito Penal, Parte Geral, 2ª edição, Juarez Cirino dos Santos)

Bem por isso, então, respeitado sempre o entendimento da Defesa, não reclama qualquer nexos entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, máxime porque acerca da edição da norma que decretou o estado de calamidade pública, advinda da autoridade competente a nível Federal e Estadual, não pode o acionado alegar inciência, pena de fazer letra morta do disposto no art. 3º, da LINDB (Decreto-Lei 4.657/42), in verbis: Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Assim, frente a tais ponderações, exaspero suas reprimendas em 1/6, sobrevivendo a pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta dias multa.

Em terceira etapa da dosimetria, conforme anteriormente fundamentado, incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual elevo as penas do acionado no equivalente a 1/6, culminando, então, no cumprimento de pena privativa de liberdade de sete anos, onze meses e oito dias de reclusão, além do pagamento de valor equivalente a setecentos e noventa e três dias multa.

Todavia, em que pese esteja respondendo a processo por crime idêntico (fls. 66/67), cuida-se de acionado tecnicamente primário, sem maus antecedentes. Também não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas. De tal forma, faz jus à causa de diminuição de penas prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

De toda forma, considerando a boa quantidade de drogas localizadas em sua posse, bem como os tipos encontrados, altamente lesivos, dentre os quais destaco, cocaína e crack, entendo por bem reduzir as reprimendas do acionado em 1/2, encerrando o cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e pagamento de multa em valor equivalente a 396 (trezentos e noventa e seis) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, penas estas que torno definitivas.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal imposta será o semi-aberto, nada absolutamente nada vindo aos autos a demonstrar a necessidade premente de estabelecimento do regime mais gravoso (fechado), de todo vedado pelo julgamento do HC nº 596.603, do STJ, rel. Ministro MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, sendo certo, ainda, que diante das circunstâncias apuradas no processo, em especial sua covardia (em não assumir suas responsabilidades), a ausência de arrependimento por seu ato indigno de afronta à Lei, diante da negativa absolutamente embusteira no momento de seu interrogatório, tudo a revelar a confiança no senso de impunidade, o regime inicial aberto me parece absolutamente insuficiente a reprimir o desvio de conduta a que a pena é destinada, descumprindo seu duplo caráter, censório e ressocializador.

Assim, o regime intermediário se mostra de rigor.

Sobre o tema: Apelação nº 0015119-63.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 19 de setembro de 2018, rel. Desembargador REINALDO CINTRA.

De toda a forma, malgrado o quantum da pena corporal aplicada, em tese, rendesse espaço à verificação do critério objetivo para a benesse disposta no art. 44, do CP, sempre respeitado o entendimento de meus pares mais experientes, eu entendo que no caso não há oportunidade para tanto, que entendo inaplicável ao caso, posto não guardar suficiência na repreensão do desvio de conduta em avaliação.

Neste sentido: Apelação nº 0005678-64.2011, rel. Desembargador De Paula Santos; Apelação nº 0002544-32.2012, rel. Desembargador Luis Soares de Mello; Apelação nº 0002580-06.2012, rel. Desembargador Souza Nery; Apelação nº 0012370-77.2011, rel. Desembargador Machado de Andrade; Apelação nº 0500193-12.2010, rel. Desembargador Camilo Léllis; Apelação nº 0001957-74.2011, rel. Desembargador Eduardo Abdala; Apelação nº 0453594-15.2010, rel. Desembargador Aguinaldo de Freitas Filho; Apelação nº 9000060-68.2011, rel. Desembargador Salles Abreu.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Ademais, tendo em conta a pena aplicada, e o tempo de custódia que descontou até então, não faz jus a qualquer benefício.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido e assim o faço para CONDENAR o réu WILLAMS AUGUSTO DA SILVA SERAFIM ao cumprimento de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de multa em valor equivalente a 396 (trezentos e noventa e seis) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06, por infringência ao disposto nos art. 33, § 4º, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sensíveis os requisitos que fundamentaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva do réu, e ainda mais agora, tendo sido condenado a duras penas, de modo que, acaso posto em liberdade, invariavelmente não se colocará de modo voluntário ao cumprimento de suas reprimendas, mantenho a prisão preventiva do sentenciado. Assim se garante a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados, transferindo-se o valor apreendido a fls. 06/07 (R\$ 17,00), e depositado a fls. 116, ao FUNAD, posto se tratar de evidente produto do comércio espúrio.

Arcará o condenado, com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do CPC.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de março de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06